

1501193-16.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE DA FONSECA TAVARES

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente. Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, ., Nossa Senhora Aparecida - CEP 15130-000, Fone: (17)

3242-3001, Mirassol-SP - E-mail: mirassol2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501193-16.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223630/2021 - DEL.POL.MIRASSOL, 19677255 - DEL.POL.MIRASSOL, 2087/21/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2223630 - DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS DANIEL DA SILVA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 01 de fevereiro de 2022, às 16:00h, na sala virtual de audiências e utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. ANDRÉ DA FONSECA TAVARES, Juiz titular da 2ª Vara da Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, comigo Escrevente ao final nomeada, estando presentes também, o DD. Promotor de Justiça, Dr. VALMOR DE MATTOS JÚNIOR; o réu CARLOS DANIEL DA SILVA, seu defensor, Dr. FAUSTO JOSÉ DA ROCHA; as testemunhas arroladas pela acusação, Thiago Gabriel de Souza e Márcio Roberto Moraes. Abertos os trabalhos, pelo MM. Juiz de Direito foi oportunizado ao réu exercer seu direito de entrevista prévia com seu Defensor de forma virtual e reservada, nos termos do artigo 185, § 5º, do CPP. Em seguida, pelo MM. Juiz foram colhidos depoimentos das testemunhas e interrogado o réu, pelo sistema audiovisual. Após, não havendo outras provas a serem produzidas,

declarou o MM. Juiz o encerramento da instrução, e, então, determinou que se passasse às alegações finais orais, gravadas pelo sistema audiovisual, iniciando-se com o Ministério Público, e na sequência, o Defensor do réu. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença. "VISTOS. CARLOS DANIEL DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 11hs37min., na altura do nº 1530 da Avenida dos Campos Maia, Vila Moreira, neste Município e Comarca de Mirassol, o acusado trazia consigo, em unidade de desígnio com o inimputável K.M.O., 9 (nove) porções de cocaína na forma de "crack" e outras 5 (cinco) porções de Cannabis Sativa L ("maconha"), com pesos líquidos de 0,81 gramas e 8,12 gramas, respectivamente, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de tráfico ilícito. A denúncia foi recebida no dia 20 de setembro de 2021. O acusado foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar. Houve a manutenção do recebimento da denúncia. Houve audiência de Instrução e apresentação de memoriais pelo Ministério Público e pela Defesa. É o relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Em primeiro lugar, transcrevo o tipo penal indicado na denúncia. Diz o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa". Transcrevo o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06: "Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação". A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls.01/02), pelo Boletim de Ocorrência (fls.15/18), pelo Termo de Depoimento (fls.03,04), pelo Termo de Declarações (fls.07), pelo Laudo Pericial (fls.32/35, 80/82), pelo Auto de Interrogatório (fls.19), pela Nota de Culpa (fls.27), pelo auto de exibição e apreensão (fls.05/06), pelo Relatório da Autoridade Policial (fls.84/85), bem como pela prova oral produzida. Passo à análise da autoria. O policial militar THIAGO falou na Delegacia que "estava com seu colega de farda SD PM MORAIS em patrulhamento de rotina pelo bairro São Bernardo, neste município, quando avistaram dois rapazes e uma moça sentados em atitude suspeita. Ao se aproximarem, um dos rapazes levantou-se, e o outro mais a moça permaneceram sentados demonstrando evidente nervosismo. Relata que no ato da abordagem e revista, localizaram nas vestes de CARLOS DANIEL DA SILVA, ora indiciado, 5 porções de maconha e 9 de crack. Já na posse do outro rapaz, menor de idade, identificado como K.M.O., uma mini-lata de goma de mascar, contendo 16 pedras de crack e uma porção de maconha e com a moça, identificada como BEATRIZ GALDIOZO BALDIN, foi encontrado um aparelho celular, que segundo ela, não era produto de crime. Em conversa com o indiciado, o mesmo confessou que as 5 porções de maconha e as 9 pedras de crack eram de sua propriedade e estava com elas a fim de vendê-las. Já em diálogo com o menor, este negou que o resto das drogas (16 pedras de crack e uma porção da maconha) fossem suas, no mesmo sentido foi a alegação de BEATRIZ, a qual disse "não saber de quem era a droga". Informa que o menor de idade disse já ter passagem pela Fundação Casa, por tráfico de drogas, e que o maior é pessoa conhecida no meio policial por frequentar biqueiras da cidade, sendo conhecido pelo vulgo de "CARIOCA". Diante da situação, capturaram e conduziram os envolvidos a esta unidade policial para deliberação da ocorrência". Em Juízo, confirmou as declarações anteriores. O policial militar MÁRCIO na Delegacia confirmou o depoimento de seu colega de farda Thiago. Em Juízo, confirmou as declarações anteriores, disse também que "o menor estava junto com o réu e estavam 3 sentados lado a lado". O réu CARLOS permaneceu calado na Delegacia. Em Juízo disse que é verdadeira a acusação. Falou que "pegou dinheiro da quinzena do seu trabalho. foi lá comprar droga e comprou de um casal. iria levar a droga para o sítio, para consumo próprio. é viciado e não tinha

intenção de vender. seu apelido é 'baianinho' e ninguém o conhece por carioca". Diante de todo o conjunto probatório, de rigor a PROCEDÊNCIA da ação penal. Os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que fizeram a abordagem do réu são similares e harmônicos entre si, incluindo aqueles dados na fase administrativa e reduzidos a termos. O réu não apresentou nada que possa justificar falsa acusação contra si. Já os policiais militares foram firmes e uníssonos em seus depoimentos. Deram a mesma versão em juízo quando do auto de prisão em flagrante. Não há qualquer razão para se duvidar do relato dos agentes públicos, que não teriam motivos para acusarem o réu injustamente, sendo seus testemunhos válidos, com o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos, sendo inquestionáveis, até que se prove o contrário, por gozarem de fé pública e quando corroborado com os outros elementos de prova. O exame químico-toxicológico (fls.80/82) realizado nos entorpecentes encontrados em poder do réu resultou em positivo para TETRAHIDROCANNABINOL e COCAÍNA, substâncias de uso proscrito no Brasil. Observo que a quantidade da droga e sua forma de acondicionamento demonstra a finalidade diversa do simples uso. Fica afastada, portanto, a tese para uso próprio, sendo irrelevante estar provada a existência de trabalho lícito, visto que a mercancia da droga pode coexistir com ele. Importante registrar também que é desnecessária a demonstração da comercialização da droga para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente. Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na construção do tipo)... não se permite ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram à sociedade não ser conveniente à sociedade a circulação de determinadas tipos de drogas". (Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed. 2007, Editora Revista dos Tribunais, p. 314/315). Ou seja, é punida a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, portanto, não há necessidade de efetiva prática do ato de comércio da substância entorpecente com a finalidade de venda. Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESES DEFENSIVAS: I) DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. II) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. III) REESTRUTURAÇÃO DA PENA . IV) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AS TESES DEFENSIVAS NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado que o réu guardava a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação por tráfico. 2. As provas produzidas ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo como acolher a pretendida desclassificação da conduta para a de uso próprio. 3. O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública, não se restringindo à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância. 4. Inviável o acolhimento da pretendida reestruturação da pena, de acordo com o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que já fixada no patamar mínimo legal, após análise esmerada de cada um dos moduladores descritos no art. 59, do CP. 5. Impossível prosperar o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea no caso em tela, eis que o acusado, na fase policial, silenciou-se e, em juízo, apesar de admitir que a droga era de sua propriedade, alegou que seria destinada ao uso e não ao tráfico, crime este pelo qual restou condenado... O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Esse delito não se restringe à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade. Daí porque não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância.". (Apelação Criminal 1.0480.11.006978-2/001; 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR WALTER LUIZ DE MELO; j. 28/08/2012). Ainda:

"TÓXICOS - TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVA SUFICIENTE - INSIGNIFICÂNCIA - NÃO APLICAÇÃO - NEGATIVA DA AUTORIA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - COMÉRCIO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A SUA APLICAÇÃO - FRAÇÃO - MANUTENÇÃO - REGIME PRISIONAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CPB - CABIMENTO NO CASO CONCRETO. - Se, apesar de o réu negar a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, as provas são aptas a comprovar os fatos havidos na denúncia, correta é a condenação nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06. - A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para tornar a conduta atípica, uma vez que o delito de tráfico, enquanto delito de perigo abstrato, apresenta grande lesividade à saúde e à incolumidade pública, o que não pode ser graduado somente pela quantidade de entorpecente apreendida. - Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé. - Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não exigindo a consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente. - É cabível a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos se o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. - A fração de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, deve ser fixada de acordo com as regras do art. 59 do CPB daquela norma antidrogas. - Adotando o novo entendimento disposto quando do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cabível é a concessão do regime prisional diverso do fechado nos casos de tráfico privilegiado. - Preenchidos os requisitos legais, cabe conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mesmo no caso de tráfico de entorpecentes." (Apelação criminal nº 1.0079.10.610239-9/001, 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR CATTÁ PRETA, j. 04/09/2012). Reconheço a causa de aumento de pena do inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/06, restou demonstrado que o acusado estava na companhia do menor no momento em que foi abordado portando o entorpecente. Diante de todo o exposto, considero que o réu praticou o crime previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06. Passo a dosar as penas, lembrando que a pena mínima nesse caso é de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, acrescida de ao menos 1/6. Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 62 da Lei de Drogas, bem como considerando a certidão às folhas 38, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade (Artigo 65, inciso I do Código Penal), que deixo de aplicar porque a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal. Na terceira fase, presente a majorante prevista no art. 40, VI da lei de drogas. Houve depoimento seguro dos policiais quanto a circunstância da presença do menor. Assim, a pena sobe em 1/6 para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da primariedade e bons antecedentes do réu. Assim reduzo aquém do mínimo, em 2/3, para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. À mingua de outras causas modificadoras da pena, torno a pena acima a pena definitiva. O regime carcerário será inicialmente o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, sendo o réu primário. Cada dia multa deverá ser calculado no mínimo legal (um trigésimo do valor do salário mínimo vigente), diante da ausência de elementos quanto à situação econômica do réu, e o valor deverá ser corrigido no momento da execução. Por fim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta, e prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação. Em caso de descumprimento do benefício iniciará o cumprimento da pena em regime aberto (artigo 33, § 1º, alínea "c", do

Código Penal). Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa do ofendido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e assim: (I) CONDENO o réu CARLOS DANIEL DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e, reconhecido o privilégio do §4º do mesmo dispositivo legal, a cumprir a pena a cumprir a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial ABERTO. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta, e prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação. As penas pecuniárias deverão ser atualizadas pelos índices de correção monetária no momento da execução, nos termos do artigo 49, §2º do Código Penal. O réu foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime inicial ABERTO. Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência. Determino a destruição do telefone celular e da mini lata de goma de mascar apreendidos (fls.05/06), nos termos do artigo 516, § 2º, NSCGJ. Por fim, quanto ao entorpecente apreendido (fls.05/06), o Juízo do Plantão Judiciário já determinou sua incineração (fls.57) nos termos do Provimento CG 45/2018 e do artigo 524-A NSCGJ, já cumprido (fls. 134/137). Oficie-se à delegacia de polícia determinando a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando-se nos autos. Custas "ex lege". Aos defensores nomeados, arbitro honorários nos termos do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil – SP em vigor. Expeça-se certidão. P.I.C. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Em seguida, pelo Dr. Promotor, pelo Dr. Defensor e pelo réu foi dito de forma expressa e verbal: renunciemos ao direito de recorrer. Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: homologo a renúncia da acusação e da defesa. O Trânsito em Julgado ocorreu nesta data. Cumpra-se a sentença, expedindo-se o necessário. Regularizados, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. NADA MAIS. A seguir foi a presente encerrada. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo MM. Juiz e dispensada assinatura das demais partes. Eu, Daniele Rodrigues Piovan, digitei. ADVERTÊNCIA:A audiência foi realizada pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. As partes poderão ter contato com o registro das gravações sem necessidade de transcrição. A gravação da audiência poderá ser visualizada no Portal e- SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo. Excepcionalmente e em razão da pandemia COVID-19, considerando a necessidade de dar celeridade aos processos de réu preso bem como levando em conta a dignidade da pessoa humana que está encarcerada sem julgamento, esta audiência de instrução foi realizada por videoconferência. O juízo e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim.